

1521274-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521274-09.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521274-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241685/2021 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 20054930 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 1476/21/139 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2241685 - 39º D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA PINTO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA PINTO, THIAGO GABRIEL FERREIRA PROFETA, NICOLAS PEREIRA e WELLINGTON BARROS EVANGELISTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos arts. 33, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 16h20min, na Travessa Roberto Montenegro, nº 108, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, associados para fins de prática de tráfico de drogas, tinham em depósito e guardavam 19 (dezenove) porções contendo 3.050,4g (três quilos, cinquenta gramas e quatro decigramas) de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, previamente associados, no dia dos fatos, os denunciados se encontravam no local acima apontado em poder de drogas, para fins de tráfico. Apurou-se também que, policiais civis receberam informação anônima dando conta de que no endereço acima apontado indivíduos estariam praticando tráfico de entorpecentes, inclusive com o serviço de entrega de drogas através do serviço de aplicativo UBER. Diante disso, os policiais saíram em diligência ao local e fizeram breve campana, até que o denunciado NICOLAS e outro indivíduo não identificado saíram no quintal da residência situada no local dos fatos. Então, os policiais decidiram pela abordagem, momento em que o indivíduo não identificado correu para o veículo Nissan/March, cinza, placas não anotadas, e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado, tendo sido possível abordar somente o denunciado NICOLAS.

Em revista pessoal, os policiais encontraram no bolso de NICOLAS uma porção de "maconha" e, indagado informalmente, NICOLAS informou que ele e o indivíduo que fugiu eram contratados para fazerem entregas de entorpecentes, que pegavam naquela residência, que era um ponto de distribuição.

Enquanto NICOLAS falava com os policiais, o denunciado THIAGO surgiu no quintal e, ao notar a presença policial, retornou para o interior da residência gritando "moiô, moiô, moiô". Assim, NICOLAS foi indagado acerca da existência de mais pessoas no interior da residência, tendo confirmado que havia mais pessoas que estavam embalando drogas para serem entregues, o que ensejou a entrada dos policiais na residência.

No interior da residência estavam os denunciados MARCUS e THIAGO, e o local exalava forte odor de "maconha". Ao serem indagados, os denunciados admitiram informalmente que havia entorpecentes no local e esclareceram que são sócios na venda de drogas. Revistando o local, foram localizadas 19 (dezenove) porções de "maconha".

Ato contínuo, enquanto os policiais ainda estavam no interior da residência, o denunciado WELLINGTON adentrou o local e foi abordado, oportunidade em que admitiu informalmente que trabalha realizando as entregas dos entorpecentes para MARCUS e THIAGO.

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretadas as suas preventivas em decisão de fls. 96/98.

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebida denúncia em 15 de setembro de 2021 (fls. 216/219).

Os réus foram citados (fls. 306/307 e 428/433), foram apresentadas respostas à acusação (fls. 461/469 e 470/475) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 490).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 572/577).

A Defesa dos acusados, por seu turno, argumentou que a apreensão dos entorpecentes foi viciada porque feita mediante coação e que não foi autorizada a visualização dos celulares dos réus. Subsidiariamente, postulou a aplicação do disposto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, absolvição quanto ao delito do art. 35 da mesma lei, por falta de provas suficientes para a condenação, pena no mínimo legal, diminuição pela confissão, regime prisional menos gravoso, direito de recurso em liberdade (fls. 578/601).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mais, afasto as teses de nulidade arguidas, vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade na conduta dos policiais civis no caso em tela.

Os agentes policiais estavam em diligências para averiguar informação de tráfico de drogas em sistema "delivery" no local dos fatos. Assim, quando da saída de um ocupante da casa, deixando o portão aberto, eles entraram e lá localizaram as drogas.

Não há, em princípio, qualquer ilegalidade na entrada para prisão pelos agentes públicos, sobretudo em casos de flagrante delito, como ocorreu no presente caso.

Como é cediço, a casa é asilo inviolável, salvo casos de flagrante delito, desastre, socorro ou determinação judicial (art. 5º, XI, da CF). E é exatamente o caso dos autos, em que os acusados tinham dentro da residência MAIS DE TRÊS QUILOS DE "MACONHA", estando caracterizada a situação de flagrância pelo crime permanente do tráfico de drogas, bem como as fundadas razões para o ingresso forçado na residência dos réus, dado o retorno da pessoa gritando "molhou, molhou", ainda mais com a denúncia prévia.

Logo, não há que se falar em nulidade, até porque, conforme já decidiram as Cortes Superiores, se revela legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, quando amparado em circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, justamente como ocorreu no presente caso.

Nesse ponto, cito, por oportuno:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO POR CRIME DIVERSO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CULPABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. VARIEDADE DE DROGAS. IMPRESTABILIDADE DA DROGA PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem solveu a questão da nulidade das provas colhidas por meio de invasão ao domicílio consignando que "além de os policiais terem afirmando que entrada na residência foi franqueada pelo próprio apelante, consta no boletim de ocorrência que se estava diante da situação excepcional de flagrante delito", ainda que por crime diverso daquele que motivou a

entrada domiciliar. 2. "O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)" ((HC 474.863/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019). 3. No caso concreto, não se pode reverter a afirmativa da Corte originária de que houve autorização do réu para o adentramento no domicílio, sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ). 4. No que toca ao regime de cumprimento de pena estipulado, embora o recorrente seja primário e a pena tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, o regime fechado mostrou-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da maior gravidade do fato (evidenciada na diversidade de narcóticos encontradas em sua residência - cocaína e maconha), nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O mesmo entendimento justifica o aumento da pena-base, pois considerada em desfavor do recorrente a culpabilidade negativa. 5. Não cabe falar em imprestabilidade da droga para o consumo (maconha), o que conduziria ao entendimento de fora apreendida apenas um tipo de entorpecente, até porque a matéria não foi destramada pelas instâncias ordinárias, e, por ausência de prequestionamento, esta Corte encontra impeço de sua análise. 6. Agravo regimental desprovido. (STF, AgRg no AREsp 1774003/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas, foram até o local onde se encontrava o réu que, de pronto, tentou empreender fuga, lançando uma sacola de plástico sobre a laje da casa em que estava, na qual foram encontrados 26 microtubos de cocaína e 4 porções de maconha. 4. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 516.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da

residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017). 3. Na espécie, a fuga de suspeitos em direção à residência, os quais possuíam em depósito quantidade significativa de substância entorpecente (142,3g de crack e 287g de maconha), e as informações no sentido de que um dos pacientes controlava o tráfico de drogas na região, legitimou a entrada dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial. 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019) Outrossim, não há que se falar em nulidade por suposta ausência de advertência pelos policiais ao acusado sobre o seu direito constitucional ao silêncio. "Isso porque, não veio aos autos qualquer prova capaz de sugerir que o réu teve esse direito violado pelos policiais militares responsáveis por sua prisão. Ao contrário, preso em flagrante e interrogado pela autoridade policial, ficou consignado que o acusado (...) desejou exercer seu direito de permanecer em silêncio (...) de maneira que, se teve condições de fazer essa opção, evidente que foi advertido sobre este e outros direitos, que são assegurados pela Constituição Federal. De qualquer forma, ainda que ficasse evidenciada eventual violação, não teria o condão de contaminar a ação penal. Primeiro porque eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal (...) Por outro lado, não ficou demonstrado prejuízo ao apelante, que, afinal, admitiu a posse de maconha quando foi ouvido em juízo, na presença de Defensor (...) sob as garantias do contraditório e da ampla defesa (...) Confira-se, a propósito: "...segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a ausência de informação acerca desse direito ao acusado gera apenas a nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP, o que não ocorreu no caso (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500072-87.2020.8.26.0073; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021).

Quanto aos aparelhos celulares, de fato não se verifica autorização judicial para sua visualização. Mas tal fato não tem o condão de macular a ação. A prova somente não será usada.

No mérito, a ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas com os acusados foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para TETRAHIDROCANABINOL (THC), listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 549/551), corroborando o auto de constatação de fls. 40/43.

Provada, portanto, a materialidade delitiva do tráfico. A materialidade do delito de associação para o tráfico resta demonstrada pela prova oral coligida aos autos. A autoria também restou incontroversa e com relação a ambos os delitos.

Na fase inquisitiva, MARCUS disse que é o responsável pelo imóvel situado na Travessa Roberto Montenegro, nº 108. Disse que compra as drogas por meio de conhecidos, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, mas não sabe os nomes dos fornecedores e nem os telefones que estes utilizam, não dizendo onde pega as drogas. Disse que ele e Thiago Gabriel são os responsáveis por comprar as drogas, as quais ficam armazenadas na sua casa. Disse que ganha cerca de R\$ 8000,00 por mês, o qual divide com seu "sócio", Thiago. Disse que Wellington é o responsável por distribuir as drogas que ficam armazenadas na sua casa. Disse que vende as drogas por meio do aplicativo WhatsApp, em um grupo que ele mesmo montou e incluiu amigos, os quais encomendam com ele. Não sabe quantas pessoas tinha no grupo do WhatsApp. Disse que Nicolas estava ali, mas ele não é responsável por distribuir as drogas e estava ali apenas para almoçar. Não sabe explicar porque Nicolas portava maconha em seu bolso, dizendo que ele não pegou a droga na sua casa. Disse que sua

namorada, Regina, não sabia de nada, embora morasse na residência (fls. 12). THIAGO afirmou que conheceu Marcus há cerca de um ano e meio. Disse que iam festas e perceberam que muita gente consumia drogas e que estas drogas eram compradas por meio do aplicativo WhatsApp. Assim, junto com Marcus Vinicius resolveram montar o próprio grupo de WhatsApp, sendo que os contatos era todos amigos que conheciam em festas. Disse que compravam as drogas de "fornecedores", mas não sabe falar quem são estes fornecedores. Disse que guardavam as drogas na casa de Marcus Vinicius, o qual era responsável pela parte de comprar as drogas e gerenciar o grupo do WhatsApp, enquanto o interrogado era responsável por dividir as drogas que eram compradas em embalagens, bem como pela contabilidade do dinheiro que a venda da droga gerava. Disse que vendiam a maconha por cerca de R\$ 40,00 a grama. Disse que Wellington era o responsável por entregar as drogas que ele separava. Disse que Wellington entregava as drogas em estações de metrô. Disse que Nicolas estava no local e é usuário de drogas, mas não estava ali para pegar e entregar drogas (fls. 13).

WELLINGTON, por seu turno, disse que é amigo de Marcus Vinicius é seu amigo e lhe ofereceu um "emprego" para que ele entregasse drogas em estações do metrô. Disse que recebia pelas entregas que fazia, dos próprios clientes. Não sabe onde Marcus Vinicius pegava as drogas (fls. 14).

Por fim, NICOLAS negou a prática do delito. Afirmou que estava na casa de Marcus Vinicius, pois foi almoçar no local. Disse que em determinado momento saiu na rua, pois sua motocicleta estava atrapalhando a passagem e uma mulher foi lhe chamar na casa. Disse que saiu na rua e foi abordado por policiais que ao revistá-lo acharam maconha em seu bolso. Nega que tenha participação no esquema de venda de drogas, sendo que apenas estava no local para almoçar. Disse que sabia que Marcus e Thiago mexiam com drogas, mas não sabe detalhes do negócio (fls. 15).

Em Juízo, MARCUS terminou por confessar a prática de ambos os delitos. Disse que o local dos fatos era sua casa. Pegava umas porções de maconha para seu uso com um rapaz que conheceu. Tirava seu consumo e vendia o resto. Tal rapaz ofereceu uma quantidade maior, para pagar menos. THIAGO é seu conhecido de festa. Ofereceu para ele se queria comprar também e revender. Comprou três quilos e pagaram R\$850,00 por quilo. Comprou junto com THIAGO. Tinham um grupo para vender para amigos e conhecidos. Vendiam R\$4,00 por grama. Embalavam em papel de presente para entregar. WELLINGTON e NICOLAS fizeram algumas entregas, mas a maioria era ele e THIAGO. Sua namorada estava na casa e ela não sabia. Estavam vendendo há três ou quatro meses. Sabia que era tráfico de drogas, mas como era mais para os amigos, "não imaginou que estaria aqui". Não tinham estrutura de venda. Não autorizou os policiais a entrarem em sua casa ou ver seu celular.

THIAGO optou pelo silêncio.

WELLINGTON disse que fez três entregas para MARCUS. Conhece MARCOS de festa "rave". Chegou no local para levar uma camiseta que tinha pegado emprestada. O portão estava aberto, entrou e os corréus estavam sentados no chão. Foi abordado pelos policiais, pegou o celular de sua mão e mandou dar a senha para ele, deu com medo porque o policial estava armado. Conhecia os outros réus da festa "rave". As entregas que fez foram em dias anteriores. Acha que ganhou R\$50,00 por duas entregas. Não desconfiou que fosse drogas, precisava muito do dinheiro. Há negócios no "Instagram", achou que era roupa, relógio ou tênis. Eram pacotes médios.

NICOLAS disse que estava na casa, que era de MARCOS, que conhece de "rolês". Sua motocicleta estava fora e ouviu buzinas, saiu para arrumar a motocicleta e foi abordado. Estava com uma porção pequena de maconha para seu próprio uso. Foi almoçar no local. Não sabia que tinha droga no local, mas sabia que "eles", MARCOS mexia com drogas. Tinha feito 2/3 entregas para MARCOS, não sabia o que era. Sabia no dia que eles estavam mexendo com drogas. Os policiais perguntaram se tinha alguém na casa, disse que tinha. Não viu THIAGO sair na casa. Ficou na sala, onde não tinha nada. Não viu o que os policiais acharam. Não participa de grupos de "WhatsApp". É motoboy, trabalha nos aplicativos de entrega. WELLINGTON e THIAGO não conhecia antes do mesmo dia. MARCOS lhe ofereceu dinheiro para fazer entregas, um valor alto, R\$50,00 por entrega, variava pela distância, mas não sabia o que era. Não tinha noção da gravidade de seus atos, "foi coisa de momento". Não ia autorizar

o acesso a seu celular, deu a senha porque foi coagido.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.

O policial civil Fabio Perego Moreira reconhecendo os réus em audiência, disse que trabalha na investigação do 39º DP, no combate ao tráfico de drogas. Receberam ligação no plantão, de que pessoas estariam comercializando drogas via “delivery”, com aplicativo. Deram ciência ao delegado de polícia, que os mandou diligenciar até o local informado, com viatura descaracterizada. A via era estreita, estacionaram na rua de cima, para visualizar a frente da residência. Permaneceram em campana velada. Em certo momento duas pessoas saíram no quintal, observaram a movimentação, e saíram para o lado externo. Um deles adentrou em um carro e o outro ficou na frente. Ficaram nervosos, e então abordaram. Quem entrou no carro se evadiu em alta velocidade, não foi identificado. Abordaram então NICOLAS que também tinha saído. Fez a busca pessoal nele. Com ele localizou pequena porção de maconha. Ele disse que a função dele era apenas entregar. Então THIAGO apareceu no quintal, o portão já estava aberto. Ele voltou para dentro gritando “molhou, a casa caiu”. NICOLAS disse que tinha mais gente lá e entraram na residência. Na sala tinha THIAGO e MARCOS, e eles tentavam esconder as substâncias que estavam no local. Eles disseram que tinha outro cômodo com mais drogas. Da cozinha saiu uma moça, que era companheira de um, acha que de MARCOS. Eles disseram que possuem grupos de “WhatsApp” onde comercializam maconha, mas mais cara, elitizada, não a “normal”. Eles postam mídias dos entorpecentes. Há uma maconha chamada “Colômbia ou Colombinha”, que é mais cara. Enquanto estavam lá chegou WELLINGTON que entrou e foi até dentro da casa. Ele disse que era “atleta”, que é o responsável pela entrega de drogas nas estações de trem. As compras são pelo “WhatsApp”, depois o pagamento é feito por Pix e aí esse atleta entrega em estações de trem ou metrô. Ele disse que MARCOS e THIAGO são sócios e eles pagam seu “serviço” ou ainda o cliente acerta. NICOLAS quando foi abordado, com um entorpecente, ele disse que apenas fazia a entrega e que havia mais pessoas na casa e estavam embalando. São embaladas em papéis de presente, diferente das “biqueiras”. Eles confessaram, MARCOS e THIAGO, mas parece que não tinham noção da gravidade da venda de drogas. WELLINGTON usava Uber ou 99 e NICOLAS entregava as drogas de motocicleta. Nos celulares deles havia vários comprovantes de pagamento via PIX, eles só entregavam para quem pagou. MARCOS e THIAGO confessaram que eram sócios na venda de drogas. A casa fora alugada como residência de MARCOS e sua companheira. A mulher de MARCOS via a movimentação, mas não entendia que era venda de entorpecentes. Uma maconha prensada nas favelas são R\$5,00 ou R\$10,00. A maconha “de qualidade” custa R\$50,00. MARCOS estava no interior da residência. Entraram porque foi localizado entorpecente em NICOLAS e porque THIAGO, quando NICOLAS estavam sendo abordado, saiu gritando “molhou”. A confissão de NICOLAS também que disse que tinha droga no local. Eles autorizaram a visualização dos celulares, tanto que eles forneceram as senhas, que constaram no Boletim de Ocorrência.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o policial civil Ricardo Gustavo Ferreira que também reconheceu os réus em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é enorme e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 19 (dezenove) porções contendo 3.050,4g de "maconha", suficientes para o comprometimento de um enorme número de usuários. Ademais, foi encontrada em poder dos réus duas balanças de precisão e embalagens usadas para o porcionamento das drogas.

De fato, foram apreendidas 3.050,4g de maconha, sendo capazes de produzir 10.894 cigarros de "maconha" e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários, ainda considerando a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Assim, tudo nestes autos revela que os réus tinham em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Ademais, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidas, bem como as condições da prisão, é possível a condenação também pelo crime do art. 35 da Lei de Tóxicos, havendo indicação de associação estável para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como a divisão de tarefas entre os acusados. MARCUS afirmou em Juízo que ele e THIAGO "compravam" as drogas para "revender aos amigos", sendo que os demais acusados, WELLINGTON e NICOLAS faziam algumas entregas para eles, demonstrando a associação estável e com divisão de tarefas entre os quatro para praticar de forma contínua o tráfico de drogas.

A propósito, cumpre ressaltar que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06: "Trata-se de crime autônomo, isto é, a sua caracterização não depende da prática de

qualquer dos crimes referidos no tipo, os quais, em ocorrendo, configurará concurso material de delitos (art. 69 do CP). Assim já decidiu o STF: 'É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no art. 14 da Lei 6.368/76 (atual art. 35), tem como finalidade cometer delitos dos arts. 12 e 13 da mesma lei (hoje, arts. 33, caput, e 34, respectivamente' (RT 773/503)". (Luiz Flávio Gomes, "Nova Lei de Drogas Comentada", Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pgs. 170/171). Inafastável, assim, a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Os réus são primários (fls. 61, 66, 71 e 74).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, com relação ao crime de tráfico de drogas; e em três anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da lei n.º 11.343/06, ambas utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de droga apreendida - mais de três quilos de "maconha"-obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. "Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução." (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: "Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado ("lex mitior"), porque meramente facultativa a situação ("...as penas poderão ser reduzidas..." g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

No mesmo sentido:

"A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente..." (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0102986-91.2014.8.26.0050. R. Des. Geraldo

Wohlers. J. 10.11.2015). destaquei.

Obviamente, quem tem três quilos de "maconha" em seu poder e monta uma verdadeira operação para venda de drogas por sistema "delivery" em grupos de "WhatsApp" integra organização criminosa.

Pelo concurso material de crimes, vez que os acusados praticaram mais de um delito mediante mais de uma ação, como as penas impostas, totalizando oito anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte dos acusados.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR os réus MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA PINTO, THIAGO GABRIEL FERREIRA PROFETA, NICOLAS PEREIRA e WELLINGTON BARROS EVANGELISTA, como incursos nas penas dos arts. 33, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de oito anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 1.200 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Considerando a pena aplicada e o caráter hediondo dos delitos, os réus não fazem jus a qualquer benefício.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei, bem como considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como toda a organização no sistema de "delivery" dos acusados, com as listas nos aplicativos de mensagens. Neste sentido:

"Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dê que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de

regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o "crack", por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

Ante a concessão de ordem de Habeas corpus aos réus pelo STJ, poderão recorrer em liberdade.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão, guias para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA